

1024322-64.2022.8.26.0562

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes

Magistrado: Daniel Ribeiro de Paula

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 11ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 28/12/2022

... configura, em tese, o crime de furto. Com efeito, sua apuração administrativa pela concessionária, para gerar alguma credibilidade, haverá de se cercar dos requisitos do flagrante criminal:

"Prestação de serviço - Energia elétrica - Apelação da autora pretendendo apenas a majoração dos honorários advocatícios - Processo sem complexidade nem condenação - Majoração indevida. - A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

11ª Vara Cível

Rua Bittencourt, 144, Santos - SP - cep 11013-300

1024322-64.2022.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1024322-64.2022.8.26.0562

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes

Requerente:

Tiago Eugenio

Requerido:

CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniel Ribeiro de Paula

Vistos.

Tiago Eugenio ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/c OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - inaudita altera pars em face de CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ. Pediu a inexigibilidade dos débitos e na reparação pelos danos morais provocados pela negativação indevida do nome do Autor junto ao cartório de Protestos e pela não comunicação da realização do serviço, o expondo a situação vexatória, requer a condenação em quantia não inferior a R\$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros desde o evento danoso e atualização monetária desde o arbitramento;

Tutela deferida.

Resposta, em síntese, que não há qualquer irregularidade no procedimento adotado diante da possibilidade de contraditório dada ao requerente, que acompanhou a visita e assinou o TOI, onde encontrava-se por escrito a possibilidade de recurso. Que o requerente, ainda que não tenha praticado a fraude se beneficiou desta e causou prejuízo e, enquanto depositário a título gratuito, é responsável pelo aparelho e não pode se eximir da responsabilidade dos danos causados. Pleiteou a

revogação da tutela, exigindo caução. Pediu pela improcedência da ação e condenação da requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório. Fundamento e decido.  
A ação é procedente.

Inicialmente cabe consignar que, tratando-se unicamente de questão de direito, passa-se ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, frisando-se, outrossim, a desnecessidade de produção de prova pericial.

Desnecessária a dilação probatória, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental, sendo desnecessária a prova oral ou pericial para esclarecimentos relevantes ao seu deslinde.

O teor do disposto no parágrafo único do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, sendo certo que “Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente descrição do Magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio do pleno contraditório” (STJ- 4ª Turma, RESP. 3047/ES, rel. Min. Athos Carneiro).

No prazo para a contestação se determinou que a concessionária deveria: 1) Juntar o histórico de consumo dos últimos 12 meses; 2) Informar se houve substituição do medidor; e 3) Informar se o medidor está preservado para fins de perícia. O silêncio quanto às determinações dos itens anteriores importará na presunção de veracidade quanto ao fato que se pretendia provar com a determinação.

Em primeiro lugar, o fornecimento de energia elétrica se caracteriza como serviço público indispensável devendo, portanto, ser prestado de forma adequada e contínua. É o que ensina o professor Hely Lopes Meirelles:  
“Serviço concedido é serviço do Poder Público, apenas realizado por particular em razão da concessão. (...) Mas, independentemente das normas pertinentes, há cinco princípios regedores de todo serviço público ou de utilidade pública de presença obrigatória na sua prestação: generalidade, permanência, eficiência, modicidade e cortesia.”.

A Lei de Concessões (Lei nº 8.987/95) e a legislação pertinente à matéria vedam a descontinuidade do serviço, de modo que não se pode admitir que a concessionária se utilize da negativa no fornecimento como meio coercitivo para o adimplemento de prestação devida pelo fornecimento de energia, fragilizando os interesses da coletividade.

Deve a concessionária se valer dos meios adequados para a cobrança do valor que julga devido. Por mais que alegue existirem indícios de fraude, os documentos que intendem comprová-la foram elaborados unilateralmente pela concessionária que, inclusive, substituiu e descartou sumariamente o medidor supostamente adulterado impedindo a produção da necessária perícia judicial que poderia constatar a ocorrência ou não da fraude de maneira isenta e imparcial.

Além disso, mesmo que se considerasse esses documentos como indícios de fraude, vivemos num Estado Democrático de Direito, onde existe a garantia do devido processo legal, que agasalha os princípios da presunção de inocência e da ampla defesa, compreendido nessa, o contraditório.

Daí porque seria inadmissível condenar a autora sumariamente, com violação desses princípios, a partir de documentos unilateralmente produzidos e “não desinteressados”, no pagamento de valor também apurado de modo unilateral, sob pena de violação à garantia constitucional do devido processo legal. Neste sentido:

"Apelação nº 991.07.010039-0, Relator(a): Des. Francisco Giaquinto, Órgão julgador: 20ª Câmara de Direito Privado do TJSP Data do julgamento: 30/06/2010, Ementa:

"Desconstituição de débito - Energia elétrica - Alegação de fraude no medidor - Cobrança de diferença de período pretérito, com base em vistoria unilateral, sob pena de corte de fornecimento de energia elétrica - Negando o consumidor a fraude, cabe à concessionária a prova positiva de sua ocorrência Valores apontados pela concessionária apurados unilateralmente, sem a necessária observância da ampla defesa e do contraditório - Inexigibilidade da dívida reconhecida - Sentença mantida. Recurso Negado".

"Apelação nº 991.08.005228-3 Relator(a): Des. Gioia Perini, Órgão julgador: 24ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Data do julgamento: 30/04/2010, Ementa:

"Apelação - Energia elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. Danos morais - TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidades - Documento unilateral - Ofensa ao Contraditório - Nenhuma outra prova técnica produzida pela ré - Insuficiência probatória da alegada fraude no medidor - Ônus da prova da concessionária - Art. 333, II, CPC - Sentença de procedência parcial do pedido (inexigibilidade de débito) mantida - Recurso da ré não provido".

Por sua vez, o artigo 37 da Resolução nº 456, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL dispõe que "A verificação periódica dos medidores de energia elétrica instalados na unidade consumidora deverá ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados".

A este mesmo respeito, o parágrafo único do artigo 38 da mencionada Resolução disciplina que "A concessionária deverá informar, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a data fixada para a realização da aferição, de modo a possibilitar ao consumidor o acompanhamento do serviço".

Finalmente, prevê a referida Resolução em seu artigo 72 que "Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências: (...) II - (...) solicitar os serviços de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, este quando se fizer necessária a verificação do medidor e/ou demais equipamentos de medição".

Não obstante a concessionária impute à autora a prática de fraude ensejadora de faturamento inferior ao correto em sua unidade de consumo, no presente caso deixou ela de produzir a prova do cumprimento da providência prevista no inciso II acima mencionado.

O já citado art. 37 da resolução em comento determina que seja obedecida a legislação metrológica quando da verificação dos medidores de energia elétrica. Entretanto, não há qualquer comprovação de que o TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) produzido unilateralmente pela apelante, tenha obedecido aos critérios estabelecidos na referida legislação, eis que, como mencionado, não fora atendido o inciso II do art. 72 daquela resolução.

Além disso, a ré não comprovou a realização da perícia técnica do medidor substituído pelo órgão metrológico oficial. A jurisprudência do E.TJSP, posiciona-se no sentido de que o TOI, per si, não é prova hábil a comprovação da irregularidade do medidor da unidade de consumo, de molde a exigir do consumidor o pagamento de fatura relativa a consumo supostamente sonegado, dada a apuração unilateral perpetrada pela Concessionária, com fundamento nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Nessa linha de raciocínio:

"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - Irregularidades na medição de consumo de energia - Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado - Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral - Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório - Prática abusiva - Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude - Cobrança arbitrária - Inadmissibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos - Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Negado provimento. (TJSP; Apelação 0006578-02.2009.8.26.0248; Relator: Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/11/2017)

"Consumidor. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré. Conforme inúmeros precedentes deste E. Tribunal, a companhia de energia elétrica não pode exigir do consumidor o pagamento de fatura relativa a consumo supostamente sonogado, por alegada fraude no medidor, que foi apurada unilateralmente, por força dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ademais, histórico de consumo que não demonstra diferença significativa nos meses anteriores e posteriores à suposta irregularidade. Sentença mantida. Ônus sucumbenciais da fase recursal explicitados. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação 1009131-76.2016.8.26.0048; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Julgamento: 11/04/2017)

"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Declaratória de inexistência de débito. Concessionária ré que promove a cobrança de valores de suposta energia elétrica consumida e não registrada em decorrência de supostas irregularidades constatadas no relógio medidor instalado no imóvel do autor. Cobrança baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido de forma unilateral. Documento que não se presta a fazer prova da alegada fraude. Inversão do ônus da prova. Aplicação da regra do artigo 6º, VIII, do CDC. Prova pericial que não foi realizada por desinteresse da ré. Concessionária que não provou a irregularidade no consumo de energia. Dano moral de pessoa jurídica não demonstrado. Reconvenção da ré improcedente. Sucumbência da ação e da reconvenção carregadas à ré. Apelo da autora provido em parte. (TJSP; Apelação 1006111-92.2014.8.26.0292; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 25ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Data do Julgamento: 16/02/2017).

O mesmo Tribunal tem decidido que a fraude, se ocorrente, dever ser comprovada por meio de perícia realizada pelos órgãos públicos com competência própria, já que a adulteração de medidor de energia elétrica configura, em tese, o crime de furto. Com efeito, sua apuração administrativa pela concessionária, para gerar alguma credibilidade, haverá de se cercar dos requisitos do flagrante criminal:

"Prestação de serviço - Energia elétrica - Apelação da autora pretendendo apenas a majoração dos honorários advocatícios - Processo sem complexidade nem condenação - Majoração indevida. - A apuração unilateral de eventual fraude no medidor de energia elétrica terá foros de verdade apenas se se acompanhar de perícia isenta, a da polícia científica ou de instituto oficial de metrologia. - Se da adulteração do medidor não há demonstração convincente, e não basta o termo de ocorrência de irregularidade, declara-se a inexigibilidade da dívida, descartada a presunção de legitimidade dos atos da concessionária, atributo da Administração direta que não se transfere com a concessão. - Ao dispor sobre revisão de fatura, a Resolução ANEEL nº 456/2000 exorbita e incide em nulidade, porque elege como uma das alternativas o "maior valor de consumo" em doze meses (art. 72, IV, "b"), acrescido de "custo administrativo" de 30% (idem, art. 73) - Recursos não providos. (TJSP; Apelação 0034737-68.2010.8.26.0005; Relatora: Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Julgamento: 18/11/2015)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Fornecimento de energia elétrica - Cobrança fundada em que o consumidor falsificou os lacres de aferição do medidor, além de adulterar seus mecanismos

internos - Comprovação, contudo, da alegada infração, mediante simples termo de ocorrência lavrado por preposto da concessionária - Documento imprestável, posto que a par de não observar os critérios estabelecidos pela legislação metrológica (artigo 37 da Resolução nº 456/2000), padece do vício de sua imposição unilateral, em flagrante violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal) - Infração que por sua peculiaridade exige que sua comprovação seja demonstrada por perícia técnica a ser efetuada por órgão subordinado a Secretaria da Segurança Pública e/ou ao Serviço de Metrologia Oficial - Exigência legal, no caso, desatendida pela concessionária do fornecimento de energia elétrica - Ação julgada procedente - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Com Revisão nº 997.914-0/2; Relator: Antonio Maria; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 29/01/2008)

Competia à parte requerida, ao constatar provável fraude no medidor, viabilizar, ao consumidor, a efetiva participação no procedimento administrativo e, com isso, preservar o contraditório, com base na normativa indicada em contestação, e auxílio do Poder Público, na medida do necessário, consoante os julgados acima transcritos.

Tal postura não foi adotada, já que a cobrança sustenta-se em prova exclusivamente unilateral, isto é, oriunda do TOI (termo de ocorrência e inspeção). Observo que a parte requerida pleiteou a designação de audiência de instrução e julgamento.

Todavia, esta não tem a possibilidade de comprovar a legalidade do procedimento, que é exclusivamente documental. Com relação ao pedido de prova pericial, concluo que esta tornou-se impossível diante da conduta da ré que durante a visita unilateralmente procedeu com alterações no aparelho, o que impossibilita avaliação apropriada do mesmo, tendo em vista que não há como assegurar que permaneceu nas mesmas condições em que se encontrava.

Quanto à pretensão da autora, de ver a ré condenada a indenizar pelos danos morais causados, tenho que ela é inafastável, pois impossível não se reconhecer a desnecessária perturbação psíquica vivenciada pela parte autora, que, além de ver-se acusada da prática de fraude, foi cobrada sob a ameaça de corte no fornecimento de bem indispensável à sobrevivência moderna, tudo em razão de falha da segunda. Mais e ainda: teve de despendar de tempo útil para reverter o abuso, sem sucesso.

Não se tratou, pois, de mero aborrecimento, mas sim de conduta abusiva da fornecedora, que acabou por tirar a tranquilidade da autora/consumidora, sendo de rigor que o dano moral seja indenizado. Atento para as condições financeiras das partes; para a extensão dos danos; para o grau de culpabilidade da ré; e para que se desestime a prática, tenho que o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) bem indeniza os danos morais causados.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido confirmando a tutela deferida. Extingo a ação, por consequência, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Assim, diante da impossibilidade de realização de perícia imparcial, não há como se inferir fraude passível de ser relacionada com o degrau de consumo. Por isso, não se pode aceitar a exigibilidade da dívida, que foi objeto de protesto, que a requerida pretende imputar à autora, impondo-se a total procedência da ação proposta, nos termos acima expostos, condenando-se a ré no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R\$ 2.000,00 (art. 85, §2º do CPC)

P.R.I.C. Deverá o autor encaminhar ao Cartório Respectivo cópia desta lauda, servindo de mandado para o cancelamento definitivo do protesto.

Santos, 25 de dezembro de 2022.